

1500846-09.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... corporal), estando envolvido com o tráfico de entorpecentes, sendo de fundamental importância acentuar que, no curso deste processo, após a concessão da liberdade provisória (fls. 99/104), o réu foi novamente detido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em 3 de junho de 2021 (fls. 174/175: processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500846-09.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

GERALDO MAGELA DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 29 de agosto de 2020, às 21h, na Rua Elídio Fortunato Fernandes, nº 1-01, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo 19 porções de entorpecente conhecido como cocaína, bem como mantinha em depósito outras 120 porções do mesmo estupefaciente, totalizando 31,35 g, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 1/4.

A decisão de fls. 81/83 recebeu a denúncia, designou audiência de instrução, debates e julgamento e determinou a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 153) e apresentou defesa prévia (fls. 150/151).

Por sua vez, a decisão de fls. 164/167 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução processual, procedendo-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e ao interrogatório do réu (fls. 198/200-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, uma vez que entendeu provados os fatos narrados na denúncia, bem como a materialidade e a autoria delitivas (fls. 203/210).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu e oferecimento de acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, rogou pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos (fls. 214/217).

É o relatório.
DECIDO.

De início, acerca do pedido formulado pela Defesa para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cumpre enfatizar que, embora o representante do Ministério Público tenha ofertado minuta às fls. 188/193, é certo que o Parquet, titular da ação penal, manifestou-se posteriormente pela inviabilidade do acordo de não persecução penal (fl. 199), uma vez que o réu responde preso a processo diverso.

Ora, da análise da Certidão Estadual de Distribuições Criminais de fls. 33/35, é possível observar que o réu foi condenado pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave contra seu genitor (Ação Penal nº 0027725-86.2016.8.26.0071, transitado em julgado) e do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (processo nº 1513695-64.2019.8.26.0071).

Ainda, conforme certificado às fls. 174/175, no curso desta demanda o réu foi detido pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500609-38.2021.8.26.0594).

Desse modo, demonstrada a prática de conduta criminal reiterada pelo réu, inviável a proposição de ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal.

Além disso, vale salientar que o representante do Ministério Público sustentou e pleiteou em seus memoriais a não concessão do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendimento este que, por si só, demonstra seu desinteresse no oferecimento do ANPP na hipótese dos autos, tornando inócua eventual remessa ao Parquet, uma vez que a pena mínima da infração, segundo seu pedido, não seria inferior a 4 anos, afastando, por consequência, o requisito previsto no artigo 28-A, caput, do CPP.

De mais a mais, deve-se ressaltar que o ANPP não se revela direito subjetivo assegurado ao réu e, ainda que proposto, o que se admite apenas para argumentar, seria refutado pelo Juízo, haja vista que as circunstâncias demonstram que não seria suficiente ao caso dos autos, em especial pela gravidade concreta do delito e, como será adiante fundamentado, o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, como também o ANPP mostrar-se-ia insuficiente para prevenção e reprovação do delito.

Pois bem. Retomando o mérito, trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5/6, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo de constatação provisória de fls. 15/18, laudo toxicológico definitivo de fls. 159/162, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática criminosa. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, quando então aceitou o serviço de transportar estupefacientes. Aduziu que trazia três porções de droga em sua mão e outras dezesseis escondidas no pé, bem como indicou aos policiais onde os entorpecentes e eppendorfs vazios estavam escondidos em sua residência. Esclareceu que o dinheiro apreendido era proveniente da mercancia ilícita e do trabalho como mototaxista. Acrescentou que foi detido posteriormente pela prática de tráfico de drogas (fls. 198/200-mídia).

O policial militar Etevaldo Carlos Pereira Júnior relatou que, no dia dos fatos, efetuava patrulhamento quando visualizou o réu parado em uma motocicleta em frente a um mototáxi e ele demonstrou nervosismo, motivo pelo qual efetuou a abordagem e encontrou em seu poder algumas porções de cocaína e quantia em dinheiro. Falou que, ao ser questionado, o réu admitiu que o entorpecente se destinava ao consumo próprio e à venda, sendo que ele efetuava entregas de droga com a utilização de sua motocicleta, assim como informou que em sua residência também havia estupefaciente, onde foram apreendidas outras porções de droga (fls. 198/200-mídia).

No mesmo sentido, o policial Thiago Guerrero Zorzetto narrou que estava em patrulhamento quando observou uma motocicleta em atitude suspeita em frente a um estabelecimento de mototáxi, pois havia informação de uso de motocicletas na prática do tráfico de drogas naquela região, quando então decidiu proceder à abordagem e encontrou 19 porções de cocaína no bolso da roupa do réu, momento em que ele admitiu que recebia pedidos de entorpecentes por telefone e efetuava as entregas; ao ser indagado acerca do armazenamento da droga, informou que havia mais estupefaciente em sua residência, sendo que, no imóvel, após colaboração do réu, foram localizados cerca de 200 eppendorfs com cocaína e outros 1.000 eppendorfs vazios (fls. 198/200-mídia).

De outra banda, a testemunha de defesa Fábio Luís Lopes da Silva contou que o réu é pessoa íntegra, discreta e trabalhadora (fls. 198/200-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial a confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Como se observa, o réu confessou a prática delitiva, a qual veio corroborada por todo o restante do conjunto probatório. Aliás, deve-se destacar que a confissão ostenta elevada carga probante a tranquilizar o espírito do julgador na formação do seu convencimento, ainda mais se confirmada pelas demais provas constantes nos autos, como no caso.

Outrossim, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se

deram os fatos, haja vista que, em patrulhamento, avistaram o réu, que demonstrou nervosismo ao perceber a equipe policial, e, ao abordá-lo, encontraram em sua posse 19 porções de cocaína e quantia em dinheiro, como também localizaram outras 120 porções do mesmo entorpecente na residência do réu, além de diversos eppendorfs vazios, após ele informar a existência dos objetos no imóvel.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos militares, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos agentes, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade do conjunto probatório a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 10/13, do auto de exibição e apreensão de fl. 14, do laudo de constatação provisória de fls. 15/18 e do laudo toxicológico definitivo de fls. 159/162, é possível observar que foram apreendidos 19 eppendorfs

de cocaína em poder do réu e outros 120 eppendorfs de cocaína em sua residência, totalizando 31,07 g, além da quantia de R\$ 268,00 e um pacote com diversos eppendors vazios, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade (31,35 g de cocaína, divididos em 139 porções) e a forma como os produtos apreendidos foram encontrados, além dos petrechos e da quantia em dinheiro encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 33: processo nº 0027725-86.2016.8.26.0071; fl. 34: processo nº 1513695-64.2019.8.26.0071). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (31,35 g de cocaína, divididos em 139 porções).

Destarte, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea. Contudo, segundo a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, de sorte que a sanção fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ademais, não se pode admitir, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Com efeito, malgrado o réu tenha cometido o crime em 29 de agosto de 2020, isto é, na vigência do Decreto Legislativo Federal nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879/2020, relacionados à pandemia do novo coronavírus, é certo, todavia, que mencionada agravante apenas deve ser considerada nos casos em que o infrator pratica o crime aproveitando-se de situação de desgraça particular ou calamidade pública. Acerca da matéria, é de fundamental importância destacar a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

"[...] mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro" (Código Penal Comentado, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Na hipótese dos autos, contudo, nada restou demonstrado no sentido de que o réu tenha se beneficiado ou aproveitado do contexto da pandemia para justamente praticar o delito, como também a calamidade pública do novo coronavírus enfrentada por toda população mundial em nada interferiu nas atividades criminosas do réu, de sorte que mantenho as penas anteriormente fixadas.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os maus antecedentes e a demonstração de que o réu se dedica a atividades criminosas (condenações pelo delito de lesão corporal), estando envolvido com o tráfico de entorpecentes, sendo de fundamental importância acentuar que, no curso deste processo, após a concessão da liberdade provisória (fls. 99/104), o réu foi novamente detido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em 3 de junho de 2021 (fls. 174/175: processo nº 1500609-38.2021.8.26.0594).

Igualmente, vale destacar a nocividade e a quantidade do entorpecente apreendido (139 porções de cocaína), fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

Dessa forma, ficam as penas mantidas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento

em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu GERALDO MAGELA DA SILVA JÚNIOR à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do valor apreendido e depositado nos autos (fl. 163), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Outrossim, decreto a perda dos demais objetos apreendidos (fl. 14: pacote contendo eppendorfs vazios), devendo ser observado o disposto nos artigos 516 e 517 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Da análise do arcabouço probatório, denota-se com clareza franciscana que o réu se dedica a atividades criminosas e está envolvido com o tráfico de entorpecentes, tanto é que no curso deste processo foi novamente detido pela prática do mesmo crime (processo nº 1500609-38.2021.8.26.0594), demonstrando descaso à liberdade que gozava, situação que caracteriza de forma veemente perigo à sociedade.

Assim, comprovada a constante prática da mercancia ilícita, como também diante do teor desta decisão e da pena ora imposta, há demonstração suficiente de que, solto, o réu voltará a delinquir. Dessa maneira, com escopo de se resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a necessidade de se evitar a reiteração de condutas proibidas, indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade e decreto sua prisão preventiva. Expeça-se, pois, o competente mandado de prisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA